

1501584-57.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON APARECIDO FERREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY

Vistos.

WELLINGTON APARECIDO FERREIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, isto porque em 06 de julho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

2ª Vara

Rua Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos - SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501584-57.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501584-57.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON APARECIDO FERREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY

Vistos.

WELLINGTON APARECIDO FERREIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, isto porque em 06 de julho de 2022, no horário e lugar indicados na inicial, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 85 porções de maconha, com peso líquido de 201,97g, e 55 porções de cocaína, com peso líquido de 37,54g, sem autorização legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 36/38).

Foi determinada a notificação do acusado (fl. 62).

O acusado apresentou resposta à acusação às fls. 80/91.

Recebida a denúncia em 20/10/2022, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 103/105).

Durante a instrução foram colhidos os depoimentos das testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 136/137).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu por entender bem demonstradas a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, bem como pelo relaxamento da prisão, tendo em vista que a mesma é ilegal ou, ainda, a revogação da prisão preventiva diante da ausência de seus requisitos, concedendo-se o direito

do acusado recorrer em liberdade.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, não há que se falar em ilegalidade da prisão do acusado, uma vez que ainda que tenha havido alguma irregularidade no flagrante realizado pela Guarda Municipal, tal circunstância não teria o condão de contaminar a ação penal, na esteira de pacífica orientação jurisprudencial e doutrinária acerca do tema. Ademais, os elementos indiciários colhidos na fase do inquérito policial foram renovados em Juízo, sob o crivo do contraditório, do que não se vislumbra qualquer mácula no procedimento.

No mérito, restaram comprovadas no curso da instrução processual a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes imputado ao réu. A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), laudo de constatação (fls. 19/22) e auto de exibição e apreensão (fl. 23), além do laudo de exame químico-toxicológico de fls.139/141.

Quanto à autoria, foi confirmada pelos depoimentos dos guardas municipais responsáveis pelo flagrante e pela condução do acusado.

Diego Gonçalves Rodrigues, guarda municipal, informou que a equipe estava descendo a rua para fazer uma ronda na quadra municipal. Numa distância de cem metros avistou o réu conversando com um rapaz na moto. Quando eles viram a viatura, o rapaz da moto saiu e o réu estava com um pacote na mão, dispensando e sentou no banco da praça. Resolveu abordar. No pacote constavam entorpecentes e dinheiro. Ele confessou que estava realizando tráfico. Indagada a mulher que foi levar comida para ele, ela também confirmou que ali era o ponto de venda dele. Ela chegou lá se identificando como esposa dele. Ela disse que ele estava nessa e o ajudava por ser viciada em droga também. Deu uma varredura no local e localizou outros entorpecentes cobertos por folhas secas. Não os conhecia antes. Ele dispensou o pacote antes de ser abordado. O rapaz da moto conseguiu ir embora. A mulher indicou onde tinham mais drogas. Ele não correu. Ele confessou. No local só estava ele, do outro lado tinha um grupinho. Foi feita revista pessoal. Foi feita revista pessoal em todos que estavam na praça. No bolso dele tinha a contabilidade do tráfico e uma quantia em dinheiro.

As declarações de Victor Hugo de Oliveira Alves, também guarda municipal, foram no mesmo sentido de seu colega de farda.

Adriana Vieira da Silva, ouvida como informante, disse que é esposa do réu. Estava com ele, mas ele apenas foi buscar a droga porque era usuário. Estava esperando o rapaz trazer a droga. Neste momento passaram duas motos e abordaram outras pessoas que ali estavam. Um dos policiais dispensou os demais e ficou conversando com um rapaz de blusa vermelha, porém ele se distanciou e foi numa obra que estava ocorrendo na praça, fez algumas perguntas, voltou, abaixou no chão, pegou a sacola, conversou com o rapaz de vermelho e o dispensou. Depois disso ele já veio e abordou o seu esposo, dizendo para ele abaixar porque estava detido. Ele pediu para o seu marido desbloquear o celular, mas ele se negou por conter foto íntima. O policial lhe agrediu com cassetete. O policial disse que a depoente não tinha direito de chamar advogado. Deram um papel para a depoente assinar. No papel estava escrito que a depoente estava liberada e podia ir embora. Não conhecia os policiais antes. Não confirma o depoimento dos policiais de que estaria levando comida para o seu marido. Não indicou onde estavam outras drogas. Ele é usuário de crack. Ele não correu. Ele trabalhava de servente de pedreiro.

A testemunha de defesa Tyara Santos Oliveira disse que conhece o réu apenas de vista. Foi fazer a unha de uma cliente em frente à praça. Não se recorda a data e o endereço do local, apenas que era em frente a uma praça. Tinha gente na praça e o abordaram. Viu os policiais saindo da mata com uma sacola. Ele estava sentado ou deitado no colo de uma moça. Acha que a sacola era preta. Acredita que era de manhã. Eram dois policiais, acho que da Rocam, estavam de moto. Eles tiraram a sacola do mato e foram em direção ao réu, mandando-o ajoelhar. Ela estava com ele. Estava em um sobrado, então dava para ver. Chegou uma viatura. Não foi à delegacia. Uma amiga sua conhece eles, então a depoente disse que poderia ser chamada pra depor se fosse necessário. Nunca viu o réu antes naquele local. Tinha mais gente

com ele, depois que eles foram ao mato pegar a sacola. Eles abordaram outras pessoas também. A distância era de uns dez metros. O mato ficava ao lado da quadra. Lembra-se de outras pessoas que ali estavam também, um gordinho e um de blusa vermelha.

Em seu interrogatório, o acusado negou a prática delitiva dizendo que apenas foi buscar drogas, pois é usuário. Ficou lá esperando na quadra porque não tinha ninguém vendendo no momento. Tinham três rapazes fumando maconha na quadra. Os policiais passaram e enquadraram os três. Um dos policiais foi averiguar e achou uma sacola de droga no canto da quadra. Um dos três estava de moto. O policial chamou-os com a sacola de drogas, conversou e liberou-os. Depois disso o policial já veio correndo com a sacola na mão dizendo que a droga era do interrogando. Não chegou a comprar drogas. Só tinha dezenove reais no bolso. Não conhecia os guardas antes. Responde a outros processos. Não conhece os outros indivíduos. Sua esposa já estava lá quando foi abordado.

Todavia, a versão negativa do acusado não tem como prevalecer, posto que evasiva e dissociada das demais provas acostadas aos autos, restando isolada.

As provas colhidas no curso da instrução processual formam um conjunto probatório suficiente a sustentar o decreto condenatório, de modo que fica afastada a tese absolutória sustentada pela combativa defesa.

O fato de a prova estar alicerçada basicamente em depoimentos de guardas municipais que efetivaram a diligência não lhe retira a credibilidade. Os guardas são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, suas declarações devem ser acolhidas sem reservas quando não se demonstra qualquer interesse concreto da sua parte na incriminação de pessoa anteriormente desconhecida, como no caso dos autos.

Há que ser prestigiado, portanto, o depoimento dos guardas municipais que foram ouvidos sob compromisso e sob o crivo do contraditório. Necessário ressaltar que a função da guarda civil municipal é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos guardas. Por tal razão, não merecem ver desprestigiadas as palavras dos agentes públicos somente pelo fato de pertencerem aos quadros da guarda civil municipal.

Ademais, chama atenção o fato de que a esposa do acusado, em solo policial, confirmou a traficância do acusado: "Questionada, relatou que WELLINGTON estava vendendo drogas na data de hoje e que apenas apontou a sacola preta, pois o viu escondendo naquele local. Não sabe dizer há quanto tempo WELLINGTON está no tráfico de drogas" (fl. 12), ou seja, percebe-se que a versão por ela dada em juízo é totalmente fantasiosa.

As circunstâncias do caso, mais precisamente a variedade e a forma de acondicionamento das drogas (maconha e cocaína), permitem inferir o objetivo do comércio espúrio de entorpecente, nos termos dos critérios descritos no artigo 52, I, da Lei nº 11.343/06, de forma a tipificar as condutas descritas no artigo 33, caput, da referida lei, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não pode ser reconhecida no caso em questão, tendo em vista que embora tecnicamente primário (fls. 115/116), o acusado responde a outros processos, inclusive um deles por crime idêntico ao imputado nestes autos, o que se permite concluir, ainda que pendente de definitividade, a vivência delitiva do agente e sua dedicação a atividades criminosas, servindo, por si só, como supedâneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Eg. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes;

iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito. Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça." (EResp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

Ainda que assim não fosse, a variedade e quantidade de porções dos entorpecentes apreendidos indicam envolvimento com atividade criminosa. Nesse sentido já decidiu o Eg. Supremo Tribunal Federal que "a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006" (HC 122594, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014). Assim, dedicando-se o acusado à atividade criminosa e não sendo o mesmo "o pequeno traficante de primeira viagem ou o traficante ocasional" visado pela legislação, resta impedida a incidência do benefício.

Diante de tais considerações, demonstradas a autoria e materialidade delitivas, passa-se à dosimetria da pena de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal. Na primeira fase, em observância ao enunciado do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que a circunstância da variedade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), bem como principalmente a natureza desta última, que é entorpecente com maior poder lesivo e alta capacidade de causar dependência, justificam a majoração da reprimenda.

Com relação às diretrizes fixadas pelo artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; é tecnicamente primário (fls. 115/116); poucos elementos foram colhidos acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorar tais circunstâncias; os motivos são os inerentes ao crime; tampouco as consequências do crime exigem maior reprovação; por último, tratando-se de crime vago, não se cogita de o comportamento da vítima ter contribuído para a prática da infração.

Diante de tais circunstâncias analisadas isoladamente, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, estes fixados em valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime, uma vez que não há nos autos elementos suficientes a aferir a real situação econômica do acusado.

Inexistindo agravantes e atenuantes e não concorrendo causas de diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, no valor anteriormente fixado.

Em que pese a Lei nº 8.072/90 impor que nos crimes hediondos e equiparados o condenado deva iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, tal dispositivo não mais se sustenta.

Além do Plenário do Eg. Supremo Tribunal Federal já haver declarado incidentalmente no julgamento do HC nº 111840 a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da referida norma, com redação dada pela Lei nº 11.464/07, também já foi pacificada a posição de que é cabível a substituição da pena privativa de liberdade no crime de tráfico por penas restritivas de direito, havendo, inclusive, Resolução do Senado Federal suspendendo a eficácia do dispositivo que a proibia (Res. 05/2012). Ora, se não há mais óbice à substituição da pena, a fortiori, não deve mais ser

impositivo o regime inicial fechado para os crimes previstos na Lei de Drogas, afinal, se é possível o mais, que é a substituição da pena privativa de liberdade, deve-se entender viável também o menos, que seria a fixação de regime inicial mais brando que o fechado, sob pena de total ilogismo do sistema. Sendo assim, de acordo com a quantidade de pena imposta, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime SEMIABERTO (art. 33 do CP).

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por ausência dos requisitos legais e, ainda que assim não fosse, a substituição não se mostraria suficiente à repreensão da conduta delitiva.

Ante o exposto, e por todo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu WELLINGTON APARECIDO FERREIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

Persistindo os pressupostos e requisitos anteriormente analisados para a decretação da prisão preventiva e, agora com maior razão diante da condenação in concreto, tendo em vista a necessidade de garantia da aplicação da lei penal e também para assegurar a ordem pública, considerando que as medidas cautelares diversas do cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram tênues e ineficazes, mantenho a custódia e nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, ficando indeferido o pedido de revogação da prisão formulado em alegações finais. Expeça-se guia de recolhimento provisória e recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Condene ainda o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, conforme legislação estadual vigente.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se guia de execução definitiva;

Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária em desfavor do réu de acordo com o artigo 50 do Código Penal e artigo 686 do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos nos termos do artigo 15, III da Constituição Federal;

Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Decreto o perdimento de eventuais valores apreendidos em favor da União.

Diante das diversas inconsistências no depoimento da testemunha Tyara Santos Oliveira, defiro o pedido do Ministério Público (fl. 137), determinando a extração de cópias e remessa para apuração de crime de falso testemunho. Providencie-se o necessário.

P.I.C.

Ferraz de Vasconcelos, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA